

0025549-97.2019.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... III DO ART. 105 DA CF/88). CRIME DE ROUBO: MOMENTO DE CONSUMAÇÃO. É firme a jurisprudência desta colenda Corte de que o delito de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel subtraída mediante grave ameaça ou violência. Noutros termos: é de se considerar consumado o roubo, quando o agente, cessada a violência ou a grave ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

Processo Digital 0025549-97.2019.8.26.0405 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0025549-97.2019.8.26.0405

Controle: 2016/001364

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

Gabriel Araujo Pena

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

GABRIEL ARAÚJO PENA, qualificado nos autos, juntamente com Gabriel Monteiro, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, com a alteração trazida pela Lei 13.654/18, artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, em 6 de janeiro de 2016, por volta das 3h30min, no interior de residência situada na Rua Raquel Queirós, 605, Santa Maria, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, agindo em concurso e unidade de desígnios entre eles e mais três indivíduos não-identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas-reservadas, subtraíram, para proveito comum: 1 aparelho de som Phillips avaliado em R\$ 850,00, 1 bebedouro Philco avaliado em R\$ 450,00, 3 televisores Samsung avaliados em R\$ 3.420,00, 2 C.P.U.'s avaliadas em R\$ 1.700,00, 1 telefone celular Motorola Moto G, avaliado em R\$ 700,00, 1 telefone celular Apple iPhone avaliado em R\$ 1.499,00, 1 telefone celular Apple iPhone 6 avaliado em R\$ 660,00, a quantia de R\$ 1.200,00 em espécie, 2 relógios de pulso Orient avaliados em R\$ 600,00, diversos documentos pessoais, peças de vestuário, bem como o veículo Honda Fit, todos os bens pertencentes às vítimas-reservadas. Apurou-se que, na data dos fatos, as vítimas-reservadas estavam em casa, quando foram acordadas por Gabriel Araújo e Gabriel Monteiro e mais três comparsas, já no interior da residência, os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, amarraram as vítimas-reservadas e seus três

filhos com cordas e passaram a subtrair os bens, bem como ameaçá-los de morte caso não entregassem mais dinheiro. Cerca de uma hora e meia depois, os assaltantes se evadiram levando também o veículo da família.

Alguns dias após, a vítima-reservada 5/2016 avistou Gustavo Conrado utilizando uma blusa de seu irmão e, em posse dessa informação, a vítima-reservada 4/2016 reconheceu Gabriel Araújo e Gabriel Monteiro como dois dos indivíduos que invadiram sua residência.

Gustavo Conrado, então, confirmou que Gabriel Araújo havia lhe emprestado uma blusa da Argentina.

A vítima-reservada compareceu à Delegacia e reconheceu fotograficamente Gabriel Araújo e Gabriel Monteiro como autores do delito.

A denúncia foi recebida em 7 de novembro de 2018 (fls. 245/247). Gabriel não foi localizado, sendo citado por edital (fls. 331/332). Posteriormente, os autos foram desmembrados para ele (fls. 338/339) e suspenso o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 341). Em 25 de junho de 2021, Gabriel foi localizado e citado pessoalmente (fls. 367). A suspensão processual foi levantada (fls. 371). Sobreveio a resposta escrita (fls. 376) e, não havendo causas de sumária absolvição, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 377/378).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas-reservadas (fls. 415/417), prosseguindo-se com o interrogatório (fls. 418).

Encerrada a instrutória, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 419). Em sede de memoriais escritos, a Dra. Promotora de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Gabriel nos termos da denúncia (fls. 422/428).

A Defesa, por seu turno, pugnou, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal extrajudicial, por inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal e, no mérito, pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal (436/441).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

A arguição de nulidade do reconhecimento extrajudicial não prospera.

Como bem salienta Guilherme de Souza Nucci:

“A preliminar de nulidade arguida pela defesa é descabida. A priori, vale constar, em sede extrajudicial não há de se falar em nulidade, mas sim irregularidade, visto tratar-se de procedimento inquisitorial, não vigente os princípios do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento informal, isto é, aquele em que não foi observada a forma específica imposta por lei, não gera nulidade, tampouco deve ser desprezado pelo julgado. Nesses casos, o reconhecimento apenas não receberá o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa, podendo constituir-se numa prova meramente testemunhal, de avaliação subjetiva, que contribuirá ou não para a formação do convencimento do magistrado” (Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Criminal 3031196-32.2013. Relator: Des. Guilherme de Souza Nucci. Julgamento: 30/6/2015). Assim, não havendo nulidade, mas mera irregularidade, a qual superada com a instauração do processo-crime, não se verifica o prejuízo, conforme o princípio *pas de nullité sans grief*.

A materialidade delitativa se consubstancia em portaria (fls. 2/5), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 6/17), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 415/417).

Gabriel não foi ouvido pela D. Autoridade Policial.

Em Juízo, negou a prática delitativa. Declarou que, em janeiro, estava em Itanhaém na casa da família e retornou somente depois do dia dez para Osasco. Não foi submetido a reconhecimento na Delegacia. Só soube da acusação quando o processo veio contra si. Não conhece Gabriel Monteiro. Já jogou bola com Gabriel Monteiro no campo do Santa Maria, mas não tinha amizade com ele. Não conhece Gustavo. Não recebeu camisa emprestada de Gustavo porque não conhece nenhum Gustavo. Em 2016, apenas estudava (fls. 418).

A negativa de Gabriel não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado, desmerecendo, portanto, guarida.

A vítima-reservada Raíssa (5/2016) informou que era de madrugada e todos estavam deitados. Por volta das 3h, escutou um barulho no corredor da casa que dava acesso ao terreno do lado. Seu irmão estava no banheiro. Continuou dormindo com sua irmã na cama. Ouviu passos no corredor e os autores abordaram todos. Levaram seu irmão até o quarto onde ele abriu a porta da varanda e os outros entraram. Foi então que percebeu o que estava acontecendo. Ficou com sua irmã que tinha cinco ou seis anos. Tentou usar o celular, mas não conseguiu. Os autores se espalharam pela casa, sendo que um deles era muito violento. Ele entrou em seu quarto, arrancando tudo e puxando a declarante da cama. Ele deixou que vestisse uma roupa, embora fosse muito ignorante. Ele amarrou a declarante com a irmã de seis anos e foram levadas ao banheiro, onde já estava seu irmão. Amarram os pés e mãos de seus pais. Colocaram seu pai de barriga para baixo. Colocaram um travesseiro na barriga de sua mãe e ela estava passando mal. Olhou o tempo inteiro o rosto deles e recorda-se perfeitamente deles. Eles fizeram tortura psicológica o tempo todo e ameaçavam de morte. Eles levaram tudo o que tinha.

Alguns estavam armados, pelo menos dois deles. O roubo durou aproximadamente duas horas. Eles saíram pelo portão, inclusive levando o carro de sua mãe. Viu uma foto no Facebook de um garoto que tinha sido colocado em liberdade. Viu que o rosto dele não era estranho e ele estava com a camiseta de seu irmão. Olhou o perfil dele e acabou localizando objetos e pessoas. Localizou os autores e o celular de sua mãe que tinha uma capinha específica e estava nas fotos. Foi até a Delegacia com as informações e as fotos. Na Delegacia foram mostradas fotos, que não reconheceu. Eles acenderam todas as luzes do imóvel. Seus pais fizeram B.O. no mesmo dia, sendo que a declarante esteve na Delegacia somente após localizar a foto na internet. Não ficou procurando por eles desde que seu pai registrou o B.O. até ter ido na Delegacia. Quando viu a foto foi que vasculhou nas redes sociais conforme informou na Delegacia. O celular era um iPhone. A capinha era um bumper que pegava apenas laterais do celular, que era dourado. O casaco que viu nas fotos era um de seu pai e outro de seu irmão. Seu pai comprou em uma fábrica e eram casacos específicos, pelo que se recorda da marca Nicoboco. Não consegue se lembrar quais pessoas usavam casaco, mas se vir a foto pode informar. Na Delegacia nunca fez o reconhecimento pessoal ou por foto dos autores. Tinha medo porque eles sabiam onde a declarante morava e estudava, inclusive quando saía da escola tinha alguns deles por lá. Depois que reconheceu eles na rede social é que soube que moravam no bairro vizinho. Foi até a Delegacia depois da prisão para fazer o reconhecimento, mas disse que não iria reconhecê-los porque sabia que moravam perto de sua casa. Descreve um como baixo, branco e cabelo liso. O outro era mais alto, pele mais morena, mas não negro. Dois eram negros e de altura mediana. O outro era branco, altura mediana e tinha tipo sardinhas.

Realizado reconhecimento, reconheceu o n. 1 (Gabriel Araújo) com 90% de certeza. Ele que abordou seu irmão com arma na cabeça e andava pela casa vasculhando as coisas (fls. 415/416).

A vítima-reservada Vandecleia (4/2016) narrou que na data dos fatos, quatro ou cinco autores, por volta das 3h entraram em sua casa, fizeram todos de reféns e levaram tudo, inclusive o carro da declarante. Eles amarram todos, colocando no banheiro.

Quando eles entraram, colocaram travesseiro na cara da declarante e não viu se todos estavam armados, mas pelo menos dois ou três estavam armados. Eles deram coronhadas, amarraram seu marido pelas mãos, colocaram arma na cara de seu filho. Levaram seu carro. Fez B.O. porque também roubaram documentos, cartões e bolsa. Duas semanas depois sua filha, que tinha visto o rosto deles, reconheceu um deles em redes sociais, este tinha sido preso. Através do perfil deste ela acabou reconhecendo os demais. Quando eles entraram a casa estava escura, sendo que eles acenderam a luz e a declarante ficou atordoada com a luz e em seguida colocaram travesseiro em seu rosto. Assim não pode reconhecer os autores. Pelas fotos que sua filha mostrou poderia reconhecer.

Foram roubados dois iPhone's e um outro celular, pelo que se recorda, Motorola. Era

possível identificar seu celular e inclusive estava no perfil da rede social que sua filha reconheceu. Pelo que se recorda seu celular era novinho e ainda não tinha comprado capinha para ele. Esteve na Delegacia após a prisão de um deles e reconheceu ele por foto. Pelo que se recorda o nome dele era Leandro.

Não conseguiria descrever fisicamente os autores que viu no dia do crime pois faz tempo e por não ter visto eles (fls. 417).

O reconhecimento de Gustavo pela vítima-reservada 5/2016 detém eficácia jurídica. Houve pormenorização da conduta dele, sendo que o acusado foi o agente que abordou o irmão da vítima-reservada 5/2016 empunhando arma e andava pela casa procurando as coisas. Neste sentido:

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contacto direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderância resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta incorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM/SP, JUTACRIM 100/250, Rel. Juiz Almeida Braga).

O reconhecimento judicial foi feito com apresentação de Gabriel e mais duas pessoas, para os fins do artigo 226, do Código de Processo Penal, sendo os agentes identificados numericamente. Foi atribuído a Gabriel o n. 1 e aos figurantes foram o n. 2 e n. 3.

A participação de Gabriel é, pois, indelegável.

Não há que se cogitar da existência da grave ameaça perpetrada por Gabriel e comparsas. Isso porque as vítimas-reservadas narraram que foram abordadas mediante emprego de arma de fogo. Ressalte-se que a vítima-reservada 5/2016 informou que Gabriel era um dos agentes que estava armado e que teria abordado seu irmão. Tentativa, à evidência, não ocorreu. A questão do momento da consumação do crime de roubo hoje se encontra devidamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não é necessária a posse tranquila da coisa roubada pelo roubador, operando-se a consumação quando detém a posse, ou seja, com a retirada da coisa que estava em poder da vítima com o emprego de grave ameaça ou violência, independentemente de locupletar-se ou não depois disso. Não é, pois, necessária a posse tranquila da res, fora da esfera de vigilância do dominus. Não é, pois, necessária a posse tranquila da res, fora da esfera de vigilância do dominus. Some-se que os bens subtraídos não foram recuperados.

O roubo está consumado no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da res subtraída mediante grave ameaça. A rápida recuperação da coisa e a prisão dos agentes não caracteriza a tentativa (S.T.J. - R.E. 77.868 - SP - Rel. Min. Félix Fischer- J. 04.03.97- DJU 14.04.97). Tal é o entendimento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CABIMENTO (ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88). CRIME DE ROUBO: MOMENTO DE CONSUMAÇÃO. É firme a jurisprudência desta colenda Corte de que o delito de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel subtraída mediante grave ameaça ou violência. Noutros termos: é de se considerar consumado o roubo, quando o agente, cessada a violência ou a grave ameaça, inverte a posse da res furtiva. Sendo desnecessário que a posse da coisa seja mansa e pacífica. Precedentes: RE 102.490, Relator o Ministro Moreira Alves (Pleno); HC 89.958, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (Primeira Turma); HC 89.653, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Primeira Turma); e HC 89.619, de minha relatoria (Primeira Turma). Por outra volta, não procedem as alegações de que houve reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ) e que não ficou demonstrada a divergência de interpretação, exigida pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da CF/88. Habeas corpus indeferido" (HC 89959, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007

PP-00070 EMENT VOL-02286-04 PP-00662 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 565-569).

A execução delitiva foi perpetrada por cinco agentes. Basta a pluralidade de pessoas, vale dizer, a concorrência de dois ou mais agentes.

Houve, portanto, divisão de tarefas durante a execução do crime e restou comprovado que o acusado e comparsa tinham a deliberada intenção de praticar o delito de roubo, configurando-se, pois, a causa de aumento do crime. Veja-se que Gabriel abordou o irmão da vítima-reservada 5/2016, empunhando arma de fogo e vasculhou a casa em busca de bens, enquanto os comparsas abordaram as demais vítimas.

Relativamente à restrição da liberdade, tem-se que devidamente caracterizada, posto que o acusado e comparsas amarraram as vítimas e as mantiveram sob seu jugo, por período de tempo, desde a abordagem, após o apossamento dos bens e fuga do local dos fatos.

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA DO VENERADO ACÓRDÃO. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. 1. PERSISTINDO O RÉU EM MANTER A VÍTIMA PRIVADA DE SUA LIBERDADE, COM ESTA CONDUTA ADICIONAL, ULTRAPASSA ELE OS ELEMENTOS DO TIPO DO ROUBO COMUM, QUE É SOMENTE MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 2. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS"

(Processo: 279906120098070007 DF 0027990-61.2009.807.0007 - Relator(a): JOÃO TIMOTEO DE OLIVEIRA - Julgamento: 13/12/2010 - Órgão Julgador: Câmara Criminal - Publicação: 10/01/2011, DJ-e Pág. 25).

Para o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao emprego da arma de fogo, basta a exibição, sendo que para fins de grave ameaça à pessoa esta utilização é um plus que torna mais acentuada a gravidade. Veja-se que os fatos ocorreram anteriormente à entrada em vigor da Lei 13.654/18. A revogação efetivada pela Lei 13.654/18 não implicou em abolição da regra específica atinente ao roubo com emprego de arma de fogo. A circunstância antes prevista no inciso I, § 2º, do artigo 157, C.P. foi expressa e pormenorizadamente contemplada na Lei 13.654/18, que deslocou sua tipificação para o inciso I, § 2º-A, artigo 157, do Código Penal, caracterizando, assim, o princípio da continuidade normativo-típica. Não havendo modificação da descrição fática contida na denúncia, mas tão-somente nova definição jurídica, reclassifica-se o delito de roubo mediante emprego de arma para o delito de roubo mediante emprego de arma de fogo, aplicando-se, entretanto, a pena da figura típica revogada, sob pena de afronta ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal prejudicial. A doutrina, ensina que: A lei anterior, quando for mais favorável, terá ultratividade e prevalecerá mesmo ao tempo de vigência da lei nova, apesar de já estar revogada (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007. Vol. 1. P. 162).

Ressalte-se que anteriormente à Lei 13.654/18 a previsão do inciso I, § 2º, artigo 157, do Código Penal era do roubo circunstanciado pelo emprego de arma, sendo que após a inovação legislativa se passou a tratar do roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, caso destes autos.

Vale dizer, a arma de fogo foi vista pelas vítimas-reservadas e não se tratou de mera simulação. Veja-se que a vítima-reservada 5/2016 reconheceu Gabriel, indicando que ele era um dos agentes que portava arma de fogo no momento da abordagem.

Como escreveu com propriedade o eminente Marrey Neto, "se a palavra da vítima pode o mais, identificar o roubador, constituiria rematado contra-senso não admitir pudesse o menos, isto é comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão" (RJDTACRIM 10/142-146, especificadamente à pág. 145. Vide, ainda, entre outros, RJDTACRIM 26/188, 23/353, 19/159, 16/148, 10/117; Julgados do TACRIM 89/443, 93/377).

O emprego da arma é circunstância objetiva do crime e, porquanto, comunica-se aos autores, independentemente de sua efetiva utilização pelos agentes.

"O emprego de arma é circunstância objetiva que agrava o roubo e, portanto, comunica-se ao co-autor, logo, demonstrado, por meio de prova insofismável, o concurso armado de dois agentes na prática de subtração patrimonial, a falta de identificação de qual deles teria feito uso da única arma apreendida não os exime de responsabilidade" (RJDTACRIM-SP 14/140).

Caracterizada, assim, está a qualificadora do emprego de arma de fogo.

Não há qualquer viabilidade de desclassificação para o delito de furto. Do conjunto probatório amealhado aos autos, verificou-se a caracterização da grave ameaça quando da subtração. Tem-se que estes elementos tipificam o crime em tela, ou seja, o roubo, cuja característica fundamental é a redução da vítima à impossibilidade de resistir pelo caráter intimidativo da grave ameaça.

Conclui-se, pois, pela procedência da ação penal, restando tipificado o delito previsto no artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I (a capitulação constante da denúncia é anterior à alteração trazida pela Lei 13.654/18, que incide no presente caso), do Código Penal.

Gabriel não agiu com intensidade dolosa anormal para os delitos da espécie que justifique a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, conforme permissão do artigo 59, do Código Penal.

Faz jus à atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal. Entretanto, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuida de agente relativamente menor à época dos fatos:

"Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundi-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade" (RJD 23/299).

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal. Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

É tecnicamente primário.

O acréscimo de pena pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo será de 3/8 (ou 9/24), em razão de serem três as causas de aumento especial previstas nos incisos I, II e V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, sendo que, com efeito, esta pluralidade indica que o delito foi mais grave que àqueles praticados à luz de uma única causa de aumento de pena. Ressalte-se que o inciso I, § 2º, do artigo 157, Código Penal, é o atual inciso I, § 2º-A, artigo 157, do Código Penal. A combinação de três causas de aumento demonstra violência

exagerada aplicada durante a prática delitiva e desvalor extremado da conduta do agente a justificar o aumento acima do mínimo-legal de maneira e entregar uma resposta eficiente e eficaz à Sociedade na coibição de práticas delitivas tais. "Em sede delito de roubo, a presença de duas qualificadoras deve ensejar um aumento da pena em 3/8, uma vez que, para se chegar a uma reprimenda justa, o Sentenciante deve observar o intervalo correspondido entre o mínimo e o máximo e variar a graduação de acordo com o número de causas especiais de aumento, e como estas são em número de cinco, a majoração será: de 1/3, se presente uma causa; de 3/8, se presentes duas causas; de 5/12, se presentes três causas; de 7/16, se presente quatro causas e de 1/2, se presentes as cinco causas especiais de aumento" (TACRIM/SP - RJTA-CRIM 36/304, Apelação nº 1.050.713/9, julgado em 02/04/1.997, 6ª Câmara, Declaração de voto vencedor: Almeida Braga).

"Com o advento da Lei 9.426/96, que introduziu duas novas causas de aumento de pena no art. 157, do Código Penal, entende-se que o ingresso dos incisos IV e V, no aludido dispositivo, as frações de aumento de pena devem ser remodeladas, tendo em vista que o aumento de 1/3 até metade deverá ser dividido por cinco. Assim, observando-se o critério progressivo adotado anteriormente, presente uma qualificadora, o aumento deve ser de 1/3; em se tratando de duas qualificadoras o acréscimo será de 3/8; concorrendo três qualificadoras o aumento será de 5/12; com quatro qualificadoras o aumento de 11/24; e na hipótese de concorrência das cinco qualificadoras, o acréscimo deve suceder no seu patamar máximo (1/2). Embora não se deva trabalhar com tais números como se fosse uma tabela fixa, é deste critério de gradação axiológica que se deve partir. Um roubo cometido com uma qualificadora não é igual a um assalto perpetrado com duas qualificadoras, ou mais. As hipóteses revelam agentes com temibilidade e potencialidade criminógenas diferentes" (TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL - AP. 1.119.107/7 - Rel. Xavier de Aquino).

In casu, mais que justificado o aumento, vez que, se não bastasse o uso de arma de fogo e a divisão de tarefas dos agentes, além de terem amarrado as vítimas, fizeram constantes ameaças de morte, bem como foram agressivos com as vítimas.

Considerando os elementos acima e os demais parâmetros contidos no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Deixo de atenuar a reprimenda pela incidência do artigo 65, inciso I, do Código Penal, por já estar em seu patamar mínimo para esta fase da dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 231. Não há outras agravantes ou atenuantes. Procedo, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao acréscimo de 3/8 em razão das causas de aumento especiais previstas no inciso II, do § 2º, e inciso I, § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, ou seja, a pena resulta em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento 13 (treze) dias-multa. Não há outras causas de aumento ou de diminuição. À míngua de qualquer outra causa legal de alteração, torno esta definitiva.

Para o condenado, determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, por ser este o regime que mais se coaduna com a natureza do crime, qual seja, roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, mediante restrição de liberdade e no interior de residência. Inclusive, diante da previsão do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Veja-se que Gabriel foi processado em data recente, tendo sido condenado, demonstrando seu desajuste à convivência social e o descaso para com a ordem institucional e constitucional.

Ora, diante das circunstâncias acima evidenciadas pela grave ameaça à pessoa, a substituição da pena privativa de liberdade é incompatível.

Trata-se de delito que causa intranquilidade coletiva e de acentuada gravidade, como o roubo com três causas de aumento de pena (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima). Pelas razões acima e pela quantidade de pena, sendo crime revestido de grave ameaça à pessoa, é inaplicável, ainda, a suspensão condicional da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO GABRIEL ARAÚJO PENA, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito,

por incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal (atual artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com a alteração trazida pela Lei 13.654/18).
O apenado respondeu a este processo-crime em liberdade, e assim poderá recorrer.
P.I.C.

Osasco, 06 de dezembro de 2022.